

引诱路人扫码并邀请其通讯录好友进入 特定通讯软件群聊，后将一定规模群组 出卖并获利行为的认定

——莫某某等非法利用信息网络案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省平顶山市中级人民法院(2024)豫04刑终9号刑事判决书

2. 案由：非法利用信息网络罪

【基本案情】

2022年7月被告人莫某某独自一人，2022年8月至10月莫某某伙同被告人刘某某，2023年2月至6月莫某某伙同他人，通过网络通讯软件联系上家获取“群二维码”(通过实名认证并包含个人身份信息的扫一扫功能，可将他人拉入聊天群)，以扫码赠送礼品的方式在人流密集区域摆摊，通过路人或代替路人操作手机扫描“群二维码”，使其进入特定聊天群，并将路人的通讯录好友一并拉入特定聊天群，拉满25人至30人的群聊人数后，将群聊以160元至180元不等的价格“交单”给上家，以此牟取非法利益。2023年2月至6月，被告人刘某某、王某某、李某某采取上述同样方式“交单”给上家。

被告人莫某某等人先后至运城市、临汾市等地作案。莫某某非法获利98994.02元，刘某某非法获利84411.58元，王某某非法获利27268元，李某某非法获利6900元。莫某某涉及“交单群”累计约799个，涉及公民个人信息约19975条；刘某某涉及“交单群”累计约496个，涉及公民个人信息约12413

条；王某某和李某某涉及“交单群”累计约279个，涉及公民个人信息约6986条。

【案件焦点】

以赠送礼品的方式，引诱路人扫码并邀请其通讯录好友进入特定群聊，待群组成员达到一定数量后，将群组出卖给上家从中获利的行为应如何定性。

【法院裁判要旨】

河南省平顶山市卫东区人民法院经审理认为：被告人莫某某、刘某某违反国家有关规定，非法获取和出售公民个人信息，违法所得均超过了50000元，情节特别严重；王某某、李某某违反国家有关规定，非法获取和出售公民个人信息，情节严重；四被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪。依照法律规定，判决如下：

一、被告人莫某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币12万元；

二、被告人刘某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元；

三、被告人王某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币32000元；

四、被告人李某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元；

五、被告人莫某某的违法所得98994.02元，被告人刘某某的违法所得84411.58元，被告人王某某的违法所得27268元，被告人李某某的违法所得6000元，依法追缴，上缴国库。

宣判后，原审被告人刘某某不服，提出上诉。

河南省平顶山市中级人民法院经审理认为：上诉人(原审被告人)刘某某及原审被告人莫某某、王某某、李某某明知他人实施诈骗等违法犯罪活动，仍帮助他人设立通讯群组，利用信息网络发布信息，提供信息的链接、二维码等

指引访问服务，获取报酬，情节严重，其行为均已构成非法利用信息网络罪。依照法律规定，改判：

一、撤销河南省平顶山市卫东区人民法院(2023)豫0403刑初240号刑事判决；

二、原审被告人莫某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币10万元；

三、上诉人刘某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币9万元；

四、原审被告人王某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3万元；

五、原审被告人李某某犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元；

六、原审被告人莫某某违法所得98994.02元，上诉人刘某某违法所得84411.58元，原审被告人王某某违法所得27268元，原审被告人李某某违法所得6900元，依法追缴。

【法官后语】

为维护信息安全，《中华人民共和国刑法修正案(九)》增设了非法利用信息网络罪。非法利用信息网络罪系将“网上”行为独立入罪，设立本罪的目的，是为了解决信息网络犯罪中带有预备性质的行为如何处理的问题，将刑法规制的环节前移，以适应惩治犯罪的需要。

行为人从上家获取特定通讯软件群聊二维码后，以赠送礼品的方式，引诱路人扫码并邀请其通讯录好友进入特定群组(俗称“地推”)，待群组成员达到一定数量后，将群组出售给上家。笔者认为，应以非法利用信息网络罪定罪处罚。具体理由如下。

一、对犯罪行为作整体性评价

对犯罪行为进行定性分析是对犯罪行为规范性认知的过程，是透过现象且

超越案件细枝末节的“价值抽象”与“价值整合”的过程。^①对犯罪行为认定是对“整体事件”的观察，思维的认知过程要采用整体性思维。

行为人从上家获取特定二维码及赠送礼品属事实性行为，组建群组、对外出售属规范性行为，系刑法评价的主要对象。将行为人认定为侵犯公民个人信息罪，是将观察点落在行为人“对外出售群组”时得出的结论，忽视了对行为人“组建群组”等其他行为的评价，未能对行为人的行为作出整体评价。“递移时间点观察法”^②认为，由于司法实践对犯罪行为的认定是“事后”的，故犯罪行为的认定要跨越行为的阶段性与局限性，要随着行为人事实要素的增加，不断扩张规范性评价的视野，从而使得出的结论在认识的不断完善中变得愈加丰实。整观行为人的核心要义，其从上家处获取二维码、将组建好的群组交给上家等行为，均是为了帮助上家设立群组。非法利用信息网络罪的增设，系对危险性明显偏高的网络预备行为独立入罪、作实质处罚，该罪的适用范围具有专属性，行为人的行为与本罪客观方面规定的“利用信息网络设立用于实施违法犯罪活动的网站、通讯群组”完全吻合，故应当认定为非法利用信息网络罪。

二、遵循罪责刑相一致原则进行处罚

帮助信息网络犯罪活动罪是将行为人实施的单纯的帮助行为在特定情况下定罪处罚。非法利用信息网络罪与帮助信息网络犯罪活动罪均包含有“设立用于实施犯罪活动的网站”的情形，有发生竞合的可能，故有观点认为，行为人的“地推”行为还可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。在此，为有效遵循主客观相一致的原则，笔者仅从主观构成要件上将关联罪名进行简要分析讨论。

非法利用信息网络罪的主观构成要件，要求行为人明知设立通讯群组用于违法犯罪，帮助信息网络犯罪活动罪要求行为人主观上明知他人利用信息网络实施犯罪，两罪的关联行为均仅限于犯罪行为；而侵犯公民个人信息的构成要件要求行为人明知自己非法获取、非法提供公民个人信息的行为会对公民个

^①周光权：《刑法总论(第三版)》，中国人民大学出版社2016年版，第236页。

^②马荣春：《犯罪行为认定的整体性思维》，载《法治社会》2020年第6期。

人信息安全造成危害即可，对其是否知道公民信息被用于何种活动未作要求。行为人实施“地推”行为时，如果其主观上明知上家将群组用于犯罪活动，行为人可能以帮助信息网络犯罪活动罪或非法利用信息网络犯罪论处，最高被判处三年有期徒刑；但如果行为人主观上只是概括性明知，不知道出售的群组被用作违法活动还是犯罪活动，仅因其非法出售通讯群组，就以侵犯公民个人信息罪定罪，最高被判处七年有期徒刑，显然不能实现罪责刑相一致。另外，帮助信息网络犯罪活动罪要求以被帮助对象的行为构成犯罪为前提，故在本案中无须考虑该罪名。

利用信息网络实施的犯罪行为有极强的扩散性与危害性，非法利用信息网络罪的立法原意旨在实现积极的刑法危险控制，利用刑事手段提前，将相关犯罪预备行为进行堵截。本罪仅规定了三年以下有期徒刑一档量刑，具有轻罪的本质属性，行为人的“地推”行为造成的社会危害性毕竟有限，往往不超过背后的实行行为、主犯行为或正犯行为可能导致的危害结果或危险状态，故以非法利用信息网络罪论处更利于实现罪责刑相一致。

总之，社交账号大多与特定自然人的身份信息、手机号码、银行账户等关联信息绑定，是公民个人信息的重要载体。“地推”组建的群组，往往成为电信网络诈骗等犯罪的工具，是电信网络诈骗犯罪的上游关键环节，在实践中出现了大量的引流团队，已形成较为稳定的黑灰产业链。“地推”引流的行为既可能为诈骗犯罪提供帮助，也可能严重侵害公民个人信息安全，必须在坚持主客观相一致原则的情况下予以打击。为有效阻断下游犯罪，即使暂时无证据证实具体实施诈骗或其他犯罪的行为人归案并受到刑事打击，并不影响非法利用信息网络罪的成立，^①满足条件的，仍要进行刑事处罚。

编写人：河南省平顶山市中级人民法院 宋红超 孙梦蝶

^①《非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪典型案例》，载最高人民法院网站，<https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/193721.html>，2025年2月24日访问。

